

1500683-14.2022.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Jane Rute Nalini Anderson

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... a venda no varejo, configurando a entrega para o consumo ou tráfico ilícito de drogas.

A conduta de qualquer dos verbos contidos no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, sendo o dolo sempre genérico. Por isso, dispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, sendo bastante a prova do conjunto de indícios e presunções ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí

Cartório da 3ª. Vara Criminal: Largo São Bento, s/nº, Centro, Jundiaí, Estado de São Paulo.

CEP nº 13201-035. Telefone: (11) (11) 2136-6223, E-mail: jundiai3cr@tjsp.jus.br.

Processo nº 1500683-14.2022.8.26.0544

Página nº de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí

Cartório da 3ª. Vara Criminal: Largo São Bento, s/nº, Centro, Jundiaí, Estado de São Paulo.

CEP nº 13201-035. Telefone: (11) 2136-6223, E-mail: jundiai3cr@tjsp.jus.br.

Processo nº 1500683-14.2022.8.26.0544

Página nº de

Vistos.

DAVI DE OLIVEIRA SOUZA, qualificado nos autos, menor de 21 anos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 8 de março de 2022, por volta das 17h30min, na Rua Miguel Barretto Mattar, altura do nº 325, Jardim Tamoio, nesta cidade e Comarca de Jundiaí, trazia consigo, para fim de tráfico, 102 (cento e dois) gramas de "crack" em pedra; 29 (vinte e nove) porções de maconha com peso de 203 (duzentos e três) gramas; 137 (cento e trinta e sete)

"ependorfs" de "crack", pesando 87 (oitenta e sete) gramas; 1 (um) invólucro plástico contendo cocaína, com peso de 279 (duzentos e setenta e nove) gramas e 166 (cento e sessenta e seis) porções de maconha pesando e 900 (novecentos) gramas, além da quantia de R\$ 271,50 (duzentos e setenta e um reais e cinquenta centavos) em cédulas de valores diversos, substâncias estas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Narra a denúncia que, na data dos fatos, o acusado recebeu um saco plástico contendo diversas porções de drogas distintas e se dirigiu ao local acima mencionado, conhecido como ponto de tráfico.

Enquanto descia a trilha de terra, o réu notou a presença de policiais militares que realizavam patrulhamento rotineiro no local e tentou fugir em desabalada carreira. Durante a fuga, Davi jogou o saco plástico ao solo. Os agentes da autoridade, então, passaram a persegui-lo, logrando êxito em detê-lo.

Em revista pessoal, os milicianos apreenderam 102 gramas de "crack" em pedra e R\$ 264,00 em notas miúdas. No interior do saco plástico, foram localizados os demais entorpecentes acima descritos.

O réu confessou a traficância.

Assim, pela quantidade e variedade das substâncias entorpecentes e circunstâncias da apreensão, foi preso em flagrante.

Notificado, o réu apresentou defesa prévia.

Analisada a defesa apresentada, a denúncia foi recebida e designada audiência de instrução e julgamento.

Na audiência, ouviram-se duas testemunhas, após o que o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em debates, o Promotor de Justiça analisou a prova e pediu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, porquanto devidamente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas. Requereu, ainda, a fixação de regime inicial fechado.

A defesa, preliminarmente, alegou ilicitude da prova, por violação ao disposto nos artigos 240, § 2º e 244, ambos do Código de Processo Penal. No mérito, bateu-se por absolvição, sob o fundamento de insuficiência probatória para o édito condenatório. Para tanto, sustentou que se trata de réu usuário de "crack" e que os depoimentos dos policiais são contraditórios. Em caso de entendimento diverso, requereu a desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 28 da Lei de Drogas; fixação da pena-base no mínimo legal; aplicação da causa de redução de pena previsto no § 4º do artigo 33 do mesmo Diploma Legal em seu patamar máximo; imposição de regime inicial aberto; substituição da corporal por restritivas de direitos e o direito de recorrer solto.

RELATADO.

DECIDO.

A preliminar suscitada não merece guarida.

Com efeito, não há falar em nulidade na abordagem do réu realizada pelos policiais militares, considerando que são eles imbuídos do poder de polícia que é próprio do Poder Público.

Sendo assim, quando esses agentes interceptam qualquer cidadão em local público e dentro dos limites legais, respeitando os direitos daquele submetido à revista pessoal, não há que se falar em nulidade, vez que se trata de atitude que faz parte da obrigação legal dos agentes da autoridade. Além do mais, esses agentes não podem se omitir diante de qualquer situação em que se vislumbra eventual prática de crime.

Nesse teor, "(...) 3. A abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública. 4. Hipótese em que a ação dos policiais foi efetiva, pois resultou na prisão em flagrante do paciente por crime permanente, o qual não se exige mandado de busca e apreensão para sua efetivação. Precedentes. 5. De acordo com a Quinta Turma deste Tribunal, "revela-se despropositado que, a toda abordagem policial, o agente estatal advirta acerca do direito constitucional ao silêncio, sob pena de torná-los todos em suspeitos de práticas delitivas" (RHC 61.754/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 07/11/2016). 6. No caso em exame, o acórdão impugnado afirmou que "tanto no interrogatório

realizado na fase investigativa quanto naquele posteriormente efetivado em juízo, houve expressa menção acerca da advertência do direito ao silêncio", razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa. 7. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige a demonstração do prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio *pas de nullité sans grief*, o que não se verifica na espécie. 8. Habeas corpus não conhecido" (STJ, HC nº 385.110/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 14/06/2017).

Não há, portanto, nulidade ou irregularidade na abordagem policial que originou a presente ação penal.

Ressalte-se, outrossim, que o inquérito é mero procedimento administrativo-informativo, razão pela qual as investigações realizadas pela autoridade policial não se confundem com instrução criminal, motivo pelo qual eventuais irregularidades por ventura nele ocorridas, não são capazes de ensejar nulidade do processo, o qual, no caso em análise, transcorreu de forma regular e sem vícios.

Oportuno, ainda, frisar que "em processo penal, vigoram os princípios de que 'nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (art. 563 do CPP)" (STJ 5ª Turma, RHC nº 38.424/MG, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 07/03/2005).

No mérito, diante da prova existente verifica-se que a denúncia deve ser julgada procedente.

A materialidade está devidamente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão das drogas e do dinheiro, bem como pelos laudos de exame químico-toxicológico, provisório e definitivo (fls. 32/35, 120/123 e 143/147), os quais confirmam que as substâncias apreendidas são entorpecentes que causam dependência física e psíquica. Incontroversa a prova de autoria.

Na fase administrativa, o réu permaneceu em silêncio. Em Juízo, negou a prática delitativa, afirmando que estava carregando uma sacola com materiais recicláveis. Não conhecia os policiais que efetuaram sua prisão. O "crack" apreendido em seu poder se destinava a consumo próprio.

Sucede que tal negativa restou isolada nos autos e não merece credibilidade.

Fortalecendo a prova de autoria, as testemunhas Mateus Ferreira dos Santos e Fernando Imperador Alves da Silva, policiais militares que tomaram parte nas diligências, sempre que ouvidas, narraram como se deu o encontro das substâncias tóxicas e do dinheiro em poder do réu, em local conhecido como ponto de tráfico. Relataram, ainda, que, informalmente, o acusado confessou que traficava no local dia sim dia não. O dinheiro e uma porção de "crack" da droga foram apreendidos no bolso das vestes do réu.

Como se vê, as palavras dessas testemunhas, ao contrário do alegado pela defesa, são suficientes para corroborar a acusação. Além do mais, trata-se de depoimentos coerentes, harmônicos e verossimilhantes, que não demonstram o propósito de querer enganar nem dão motivo de suspeição. Como seu valor não se põe em dúvida, eles podem ser considerados fonte de convicção (ver: CF, 93, IX; CPP, artigo 155, caput; RTJ, 143/160 e 201/637).

Quando não bastasse, em casos de aplicação da Lei de Drogas, a jurisprudência amplamente majoritária não tem feito restrição ao testemunho de qualquer policial, quando o seu depoimento estiver em harmonia com os demais elementos de prova.

Para enfraquecê-lo é imperioso demonstrar motivo sério e concreto, sendo insuficiente a mera alegação de parcialidade desacompanhada dos respectivos elementos de convicção. E não haveria motivo de eventual trama dessas testemunhas para incriminar falsamente os acusados, restando demonstrada nos autos a traficância.

Nesse sentido, "A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado. É preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas" (STF, HC 74.522-9/AC, 2ª Turma, rel. Min. Maurício Corrêa, DJU, 13/12/96, pág. 50.167).

Assim também decidia o extinto Tribunal de Alçada Criminal, "Inaceitável e

preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (RT 732/632).

Examinando os erros, as incoerências e as contradições de testemunhas, pontifica o clássico Borges da Rosa: "(...) os erros são elementos constantes na prova testemunhal; a testemunha não sujeita a erros não existe, porque o depoimento, o testemunho, é uma reprodução pessoal e lacunar da realidade. As divergências e contradições entre os depoimentos de duas ou mais testemunhas são, portanto, naturais; o que não é natural é a conformidade dos mesmos, que faz supor a identidade de inspiração, o concerto prévio, o eundem premeditatum sermonem, de que fala FRAMARINO MALATESTA, na sua Lógica das Provas" (v. Borges da Rosa, Comentários ao Código de Processo Penal, 3ª ed., RT, 1982, pág. 322). "O testemunho demasiado perfeito é que deve gerar desconfiança" (cf. Almeida Júnior, Lições de Medicina Legal, pág. 526).

Dessa forma, as pequenas divergências nos aspectos secundários, porém com coincidência nos essenciais, entre os relatos das testemunhas não lhes retiram o valor probatório.

Note-se, agora, que as substâncias tóxicas foram apreendidas divididas e acondicionadas em porções, para a venda no varejo, configurando a entrega para o consumo ou tráfico ilícito de drogas.

A conduta de qualquer dos verbos contidos no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, sendo o dolo sempre genérico. Por isso, dispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, sendo bastante a prova do conjunto de indícios e presunções envolvendo o acusado.

É possível, em consequência, o uso de prova indiciária, a qual também está em harmonia com o princípio do livre convencimento do juiz (cf. artigos 239 e 157, ambos do Código de Processo Penal).

Não é caso de desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 28 da Lei de Drogas como pretende a defesa, tendo em vista a quantidade de tóxico apreendida, o que desautoriza a pretendida desclassificação.

Dessa forma, insubsistente a alegação da defesa de fragilidade das provas, porquanto bem caracterizado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Concluindo, o conjunto probatório é suficiente para dar credibilidade à acusação.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e o faço para CONDENAR o réu DAVI DE OLIVEIRA SOUZA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

Observando os elementos norteadores contidos no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, a fixo a pena-base acima do patamar mínimo, no percentual de 1/4 (um quarto), somando 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, considerando a quantidade e variedade de tóxico apreendida em poder do réu, além de responder a outras ações penais, uma delas por delito idêntico (fls. 115/116).

Note-se que a "Quantidade e qualidade da droga apreendida é circunstância que deve ser sopesada na primeira fase de individualização da pena, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006" (cf. STF, 2ª Turma, RHC 111.440/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe-094, 15/05/2012).

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Não é caso de aplicação da causa especial de diminuição, prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, tendo em vista a quantidade e variedade de droga apreendida, o que demonstra a dedicação do acusado ao crime.

A pena privativa de liberdade ora aplicada será cumprida em regime fechado, uma vez que se trata de crime gravíssimo, eis que a real intenção do traficante é amealhar o maior número de vítimas, comprometendo toda a sociedade.

Observe-se, por oportuno que mesmo a fixação da pena-base no mínimo legal cominado a espécie não é fator determinante para o estabelecimento do regime inicial de cumprimento de pena.

Analisando a última parte do artigo em comento “estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime” tem-se que o regime inicial fechado é o único satisfatório em relação à gravidade objetiva do fato, uma vez que a conduta do acusado colocou em risco, não apenas a saúde do usuário, mas, também, a integridade de toda a sociedade.

O réu não poderá apelar em liberdade, eis que continuam presentes os requisitos autorizadores de sua custódia cautelar.

Autorizo a destruição do entorpecente apreendido nos autos, oficiando-se.

Determino o perdimento do dinheiro em favor da FUNAD.

Assim, fica o réu DAVI DE OLIVEIRA SOUZA, condenado à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime fechado, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, seja o nome do réu lançado no rol dos culpados.

P.I.C.

Jundiaí, 26 de maio de 2022.

Jane Rute Nalini Anderson
Juíza de Direito